

1512935-47.2019.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes contra as Relações de Consumo

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... ficou determinada a incidência das penas do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006): reclusão, de cinco a quinze anos (cf. STJ, AI no HC 239.363/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 10/04/2015).

Desta forma, observando-se os elementos dos autos e aqueles norteadores previstos nos arts. 59 e 60, do Código ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512935-47.2019.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512935-47.2019.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra as Relações de Consumo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2230651/2019 - 03º D.P. LIMEIRA, 4044208 - 03º D.P. LIMEIRA, 1321/19/812 - 03º D.P. LIMEIRA, 1320/19/812 - 03º D.P. LIMEIRA, 2230651 - 03º D.P. LIMEIRA, 1321/19/812 - 03º D.P. LIMEIRA, 1320/19/812 - 03º D.P. LIMEIRA, 2230651 - 03º D.P. LIMEIRA, 1321/19/812 - 03º D.P. LIMEIRA, 1320/19/812 - 03º D.P. LIMEIRA, 2230651 - 03º D.P. LIMEIRA, 1321/19/812 - 03º D.P. LIMEIRA, 1320/19/812 - 03º D.P. LIMEIRA, 2230651 - 03º D.P. LIMEIRA, 1321/19/812 - 03º D.P. LIMEIRA, 1320/19/812 - 03º D.P. LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO HENRIQUE DE GASPARI FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

TIAGO HENRIQUE DE GASPARI FERREIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 273, § 1º § 1-A, do Código Penal e artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 02 de julho de 2019, por volta das 11 horas, na Estrada Lim-112, nº 51, Vila Nova, no município e comarca de Limeira, o acusado tinha em depósito para vender produto saneante adulterado consistente em detergente em pó acondicionado em diversas caixas da marca "OMO".

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e local, o réu tinha em cativeiro espécimes da fauna silvestre, sem devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida.

Segundo se apurou, na data e local dos fatos, o acusado tinha em depósito para a venda detergente em pó adulterado acondicionado em caixas da marca "OMO", bem como mantinham em cativeiro aves silvestres consistentes em 02 galos da campina, 12 trinca ferro, 02 pintassilgos, 03 tico-ticos, 01 tico-ticos rei, 01 sabiá coleira e 02 coleirinhas.

Guardas Municipais receberam informações de que no local havia indivíduo criando aves silvestre e para lá se deslocaram. Chegando no imóvel, os guardas tiveram a entrada franqueada e encontraram várias gaiolas e as aves.

No local também foi verificada a existência de uma sala com diversas caixas de sabão em pó da marca "OMO" (abertas e fechadas), uma betoneira com resquícios de sabão em pó e sal de cozinha, sal moído, diversos frascos de cola, estiletes e vasilhames contendo produtos químicos. A autoridade sanitária foi acionada e compareceu no local, que foi interditado.

No dia 15 de julho de 2019, quando a autoridade sanitária retornou ao local para dar continuidade nos procedimentos de vigilância sanitária, constatou que o lacre de interdição havia sido violado e os produtos interditados retirados sem autorização, impedindo assim a perícia de todos os produtos ali armazenados.

Entretanto, nesta oportunidade, foi colhida uma amostra do detergente em pó encontrado no local e, conforme exame realizado pela empresa responsável pela marca "OMO", concluiu-se que a amostra não se caracteriza como OMO LP, pois todos os parâmetros analisados estão fora da especificação, sendo que 54,6% da composição é de Cloreto de Sódio (sal de cozinha).

A denúncia foi recebida em 28 de setembro de 2020 (fls. 181/183).

Foi deferido pedido de habilitação para assistente de acusação por parte da Unilever Brasil (fls. 212).

O réu foi citado (fls. 228) e apresentou defesa escrita (fls. 232/233).

Foi mantido o despacho de recebimento da denúncia (fls. 234/235).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e o acusado, interrogado ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se.

Alegações finais escritas do Ministério Público (fls. 261/265), do assistente de acusação (fls. 267/278) e da Defensoria Pública (fls. 282/286).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou provada pelos boletins de ocorrência (fls. 07/08, 09/10 e

12/13), termo de apreensão (fls. 24/25), laudo pericial em local de crime ambiental (fls. 26/39), laudo de análise produzido pela Unilever Brasil (fls. 40/42), documentos (fls. 118/128), auto de exibição e apreensão (fls. 146), laudo pericial complementar de produto (fls. 147/152), bem como pelos depoimentos e declarações colhidos durante a persecução penal.

A autoria também é certa.

Perante a autoridade policial, o acusado disse que trabalha no ramo de produtos de limpeza. Ele adquire produtos em grande quantidade, conseguindo assim um valor abaixo dos praticados no mercado e depois os empacotava sem nenhuma marca e pacotes de um quilo em embalagens transparentes e revendia, sendo esta a única fonte de renda da família. Quando foi interditado o local de trabalho, foi feita a alegação de que ele adulterava marcas conhecidas no mercado como o sabão em pó OMO, haja vista a quantidade que tinha no local. Por não ter nenhuma outra fonte de renda e por ter notas fiscais de compra do produto, ele acabou vendendo o material, para se sustentar. Suas atividades ainda continuam suspensas. Quanto aos pássaros, informou que participa de competição. Possui pássaros com anilhas e registro, porém, alguns não estavam registrados, motivo pelo qual foram apreendidos, inclusive com as gaiolas. Disse que os pássaros são bem cuidados e, no momento em que a Guarda Municipal esteve em sua casa, ele franqueou a entrada (fls. 15).

Em Juízo, o acusado disse que tem 33 anos. É solteiro. Trabalha com frete. Mora com seus pais. Não tem antecedentes criminais. Os guardas bateram no portão. A denúncia era a respeito de pássaros. Morava na chácara. Metade dos animais tem registro, os que eles levaram não tinha registro. Sabe que é crime ambiental, é um hobby que tem desde a infância. Os guardas entraram no barracão, não negou a entrada. Havia caixas abertas, sacos estourados. Fabricava sabão em pó. Tem uma betoneira e materiais químicos. Faz do zero o material pra limpeza. A cola estava lá embaixo, o guarda municipal pegou de outro local. Os guardas deduziram que ele alterava o material OMO. Explicou tudo aos policiais civis. Falou como batia o material e produzia o sabão em pó. Não tem como colocar sal na caixa de OMO, não tem como adulterar o produto OMO. A ocorrência policial atrapalhou as vendas, teve que parar tudo. Não tinha empresa legalizada. Tinha notas fiscais, tinha produtos vencidos que rasgava. Isso é achismo da guarda municipal. Realizava sabão em pó com produtos químicos. Entra com corante e essência para azular, depois entrava com sal. Vendia o material de porta em porta. Tinha caixas de sabão em pó da marca Omo. Faltava quinze dias pra vender, comprava produtos vencidos, molhados, tudo que iria vencer era comprado por ele, pegava de atacadistas locais. Vendia para lavanderias locais em sacos de 5 kg. Pagava de 60 a 70% mais barato, misturava tudo e produzia um sabão novo, de sua autoria. Violou o local porque precisava trabalhar (mídia).

Vejamos o teor da prova oral.

O guarda civil municipal José Ronaldo da Nobrega disse que foram até o local. Fizeram contato com os moradores, a entrada foi franqueada. Foram verificar um galpão perto da casa e lá havia muito detergente em pó, tudo era embalado. O local era uma central de adulteração. Solicitaram perícia. Encontraram pássaros de forma irregular. Quem o atendeu foram os moradores da residência. As aves estavam na casa. Não se recorda se o acusado estava ou se chegou depois. Indagado, o réu disse que pegava produtos de outro local que estavam prestes a vencer e lá era misturado com outros produtos, aumentava a quantidade. Não havia qualquer documentação quanto aos pássaros, eram da fauna silvestre. Havia embalagens abertas e fechadas, além de quantidade grande a granel. Havia betoneira com resquício de sabão em pó, assim como sal de cozinha, vasilhames e rolos de fitas crepes, tudo utilizado para selar o produto. Houve interdição naquele dia. Não ficou sabendo que o lacre foi violado. Solicitaram perícia no local, fizeram o trabalho, não teve mais conhecimento do que ocorreu. Houve obtenção de amostra do produto adulterado (mídia).

O guarda civil municipal Wellington Correia da Silva disse que a ocorrência foi no bairro do Pinhal. O réu tinha com ele algumas aves silvestres sem documentação. Encontraram um depósito onde havia sabão em pó. Tudo era comprado em grande quantidade, lá era adicionado sal e era revendido para lojas de lavagem de roupas. Não foi apresentado qualquer material. Quanto às aves, não havia licença daqueles animais, a licença era antiga e de outras aves que ali não estavam. Das aves apreendidas não tinha qualquer autorização. As aves da fauna silvestre foram recolhidas. O local do encontro do material saneante foi interditado. Ficou sabendo depois que houve rompimento e não tinha mais material no depósito, tudo foi retirado, não participou dessa diligência. Referente aos produtos, foram encontrados várias caixas de sabão em pó da marca OMO, sacos de sal. Tudo aquilo era revendido. Sabe que a quantidade era grande. Havia caixas fechadas e algumas abertas descoladas com cuidado. No local havia estilete pra abertura das caixas e cola pra fechamento. Os materiais eram comprados de atacadistas, produtos fora da validade, e com isso era adicionado sal, ficava mais forte e era vendido para lavanderias locais. O acusado estava no local e quem assinou a documentação de vistoria foi ele (mídia).

Quanto à ação dos guardas municipais, tem-se que perfeitamente válida. É cediço que o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal estabelece que a guarda municipal será destinada apenas à proteção de bens, instalações e serviços dos Municípios, não tendo ela, portanto, a função de garantir a segurança, bem como investigar a prática de crimes. No entanto, referida limitação não significa que a guarda municipal não possa prender em flagrante quem estiver cometendo um delito. "(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "latu sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP – Rel. Min. Moura Ribeiro – j. 27.05.14; RHC 45.173/SP – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 26.05.14 e HC 109.105/SP – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – j. 23.02.10)(...) (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

A testemunha Marcio Luis Facina Fuschi disse que é autoridade sanitária e foi acionado pela Guarda Municipal para realizar uma inspeção sanitária, em uma chácara onde o acusado tinha uma fábrica de sabão em pó. O réu abria as embalagens e

adicionava sal para gado nos produtos de limpeza. O lacre da interdição foi violado. Participou da interdição cautelar, foi ele quem fez. Indagado, o acusado disse que não tinha empresa regularizada. O réu alegou que retirou o material na segunda ocorrência porque não poderia esperar. Foi acompanhado de guarda municipal na primeira vez, havia um pessoal do meio ambiente. Na segunda visita foi acompanhado de um fiscal tributário. Havia caixas de OMO abertas para serem jogadas na betoneira, assim como caixas fechadas. Havia sabão na betoneira. Localizaram frascos de cola, estiletes, vasilhames. Depois da mistura, havia cola branca de papel pra vedar a embalagem. A respeito do material, o acusado disse que comprava sabão em pó e que era adicionado sal, depois reembalando pra fins de venda ao comércio. Não havia qualquer autorização de funcionamento e nem de manipulação, nada foi mostrado quando instado, o réu não tinha sequer empresa constituída, era ele o responsável. No local, além do acusado, estava a mãe e o outro parente do denunciado. Na hora que chegou não viu ninguém manipulando. Os guardas chegaram primeiro, ele foi acionado depois. Não se recorda a quantidade exata, mas havia muito produto. De imediato fez a interdição do local para que nada fosse mexido, a vigilância sanitária não tem como fazer a análise desse produto, tiveram que requisitar junto a outro laboratório. Foram procurados pelo advogado da Unilever para que fosse verificada uma pequena amostra, o acusado deu permissão, não tinha mais produto e conseguiu obter uma amostra que estava dentro da betoneira, pois o réu de lá tirou os produtos. O acusado autorizou a coleta da amostra, ele não quis amostra pra contraprova. O advogado da Unilever recebeu uma amostra. Fizeram a interdição porque produtos saneantes estavam no local sem identificação, não havia qualquer licença pra manipular esse produto. O material não adulterado seria devolvido ao réu e o que fosse adulterado seria descartado. O local foi violado, registrou boletim de ocorrência, não havia mais produtos lá dentro, foi o acusado quem tirou, houve descumprimento de ordem. Os guardas ambientais recolheram os pássaros que estavam sem identificação e sem anilha (mídia).

Passo a analisar os crimes separadamente.

Artigo 273, § 1º § 1-A, do Código Penal

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram a materialidade e a autoria do crime de falsificação de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais descrito na denúncia.

Não há dúvidas da prática da infração penal pelo acusado, o que se extrai especialmente pelo depoimento da testemunha de acusação Marcio Luis Facina Fuschi e pelos laudos juntados aos autos.

No local dos fatos, foram encontradas diversas caixas de sabão em pó da marca "OMO", betoneira com resquícios de sabão em pó e sal de cozinha, sal moído, diversos frascos de cola, estiletes e vasilhames contendo produtos químicos. O local foi interditado.

Dias depois, foi colhida uma amostra do detergente em pó encontrado no local e, conforme exame realizado pela empresa responsável pela marca "OMO", concluiu-se que a amostra não se caracteriza como OMO LP: "A amostra analisada não caracteriza-se como OMO Lavagem Perfeita, pois todos os parâmetros analisados estão fora de especificação, sendo que mais de 50% da composição é de cloreto de sódio (sal de cozinha)" (fls. 42).

Os laudos periciais acostados aos autos descreveram com precisão os produtos localizados, o estado da matéria-prima e produtos encontrados no imóvel de propriedade do acusado.

Os argumentos apresentados pelo acusado foram todos refutados pelas testemunhas ouvidas em Juízo, as quais foram enfáticas em atribuir ao acusado a autoria do

delito ora apurado, narrando com riqueza de detalhes a forma como se deram os fatos, com suas narrativas corroboradas pelos laudos periciais juntados aos autos.

Ainda, a vasta documentação encartada aos autos comprova que o réu não possuía qualquer autorização e registro exigido no órgão de Vigilância Sanitária. Por fim, a perícia realizada no material coletado, por sua vez, constatou que o material guardado em depósito pelo acusado era produto saneante adulterado.

No mais, as teses fáticas levantadas pela Defensoria do acusado, em alegações finais, não podem prosperar, devendo ser repelidas, porquanto não encontram amparo em elementos probatórios relevantes, vez que confrontam com os demais elementos de prova produzidos, que formam um contexto harmônico, coerente e robusto a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98

São robustas as provas da prática delitiva, considerando que a prova oral confirmou, por meio dos relatos firmes e seguros de testemunhas, que o réu mantinha em sua residência espécimes da fauna silvestre nativa, sem a devida permissão, licença ou autorização.

Com o acusado foram encontrados 02 galos da campina, 12 trinca ferro, 02 pintassilgos, 03 tico-ticos, 01 tico-ticos rei, 01 sabiá coleira e 02 coleirinhas, acondicionados em gaiolas, conforme devidamente constatado pelos guardas municipais quando de sua inspeção.

Assim, pelas provas amealhadas, restou comprovado que o réu tinha em cativeiro, sem a devida autorização da autoridade competente, espécimes da fauna silvestre, violando, desta forma, a norma prevista no art. 29, §1º, III, da Lei n. 9.605/1998, sendo de rigor sua condenação neste específico delito.

Do mesmo modo, incabível, na espécie, o perdão judicial.

Não se olvida que o §2º do art. 29 da Lei nº 9.605/1998 faculta ao juiz que, diante das circunstâncias do caso concreto, deixe de aplicar a pena no caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção.

No entanto, o dispositivo mencionado diz que para a concessão do perdão judicial devem ser consideradas as circunstâncias do caso concreto e, no presente, tenho que elas não se mostram favoráveis, mostrando-se inviável a benesse. Deve ser ressaltado que foram apreendidas diversas aves em poder do acusado, e não apenas uma, e isso deve contar em seu desfavor.

A conduta do acusado é típica, ilícita e culpável. Não incidem na espécie causas de exclusão da ilicitude ou culpabilidade, encontrando tipicidade na exata correspondência com o delito previsto no artigo 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98.

Evidenciada a prática dos delitos, passo, à luz dos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Artigo 273, § 1º § 1-A, do Código Penal

Concernente ao crime de falsificação de produto saneante, necessário que haja a incidência, ao presente caso, do teor do julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal (cf. STF, RE 979962, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-113 DIVULG 11-06-2021 PUBLIC 14-06-2021), em que se reconheceu a inconstitucionalidade do preceito secundário do crime previsto no art. 273, do Código Penal, por ofensa aos

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em razão de a pena do referido delito ser superior a penas de outros crimes graves.

Assim, ficou determinada a incidência das penas do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006): reclusão, de cinco a quinze anos (cf. STJ, AI no HC 239.363/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 10/04/2015).

Desta forma, observando-se os elementos dos autos e aqueles norteadores previstos nos arts. 59 e 60, do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não reconheço qualquer agravante. Por outro lado, deixo de aplicar qualquer atenuante.

Na terceira fase, tendo em vista a incidência da pena do crime de tráfico como já fundamentado acima e sendo o réu primário, de bons antecedentes e não havendo prova de que integra organização criminosa, aplico a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4ª, da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a reprimenda em 1/2 (metade), tornando-se definitiva a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa.

Aplicando o redutor, cito os seguintes precedentes: STJ, RvCr 5.627/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2021, DJe 22/10/2021; EDcl no REsp 1823328/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 04/06/2020.

Para que fique bem claro, na derradeira etapa do sistema trifásico, deve ser levada em consideração a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, causa esta que, uma vez verificados seus requisitos, deve ser aplicada.

A este respeito, deve ser acolhido o seguinte preceito doutrinário:

“Dispõe o parágrafo, em sua parte final, sobre condições negativas de que o agente não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Toda prova negativa é difícil, de modo que militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, no caso, é do Ministério Público no sentido de demonstrar a reincidência, os maus antecedentes e a participação em atividades criminosas ou organização criminosa. Não importa que a prova seja difícil para o Ministério Público. Mais difícil seria para o réu que, por sua vez, tem o direito de não ser condenado a não ser que haja prova, ou receber, sem prova, uma pena maior quando a lei permite uma pena mais branda” (GRECO FILHO, Vicente e RASSI, João Daniel. Lei de Drogas Anotada. São Paulo: Saraiva, 2008).

O valor do dia multa será no mínimo legal.

Considerando o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no acórdão proferido no HC 118.553/MS, no sentido de que o delito de tráfico de drogas privilegiado não possui natureza hedionda, revejo meu entendimento para admitir à fixação de regime inicial carcerário mais brando aos condenados pela prática daquela infração penal. Dessa forma, fixo o regime inicial semiaberto para o caso em questão. Para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, conforme Súmulas 440/STJ e 718 e 719 do Colendo STF, que assim dispõem:

Súmula 440/STJ: Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.

Súmula 718/STF: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.

Súmula 719/STF: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena

aplicada permitir exige motivação idônea.

Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por força da restrição imposta pelo art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como pela suspensão condicional da pena em função da vedação do art. 44, da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, a partir do julgamento do HC 97.256/RS pelo STF, declarando incidentalmente a parcial inconstitucionalidade do § 4º do art. 33 e do art. 44, ambos da Lei nº 11.343/2006, o benefício da substituição da pena passou a ser concedido aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos insertos no art. 44 do Código Penal.

Não basta a primariedade do acusado para fazer jus à substituição, pois deve o juiz levar em conta, além da natureza e da quantidade da substância ou do produto, a personalidade do agente e a conduta social do agente.

Nesses termos, entendo que o comportamento do réu em Juízo leva a crer que sua personalidade, no que tange à maturidade e a responsabilidade, torna inviável a conversão da pena em restritivas de direitos.

Artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98

Na primeira fase, observando-se os elementos dos autos e aqueles norteadores previstos nos arts. 59 e 60, do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não reconheço qualquer agravante. Por outro lado, deixo de aplicar qualquer atenuante.

Ausentes quaisquer causas de aumento.

A pena de multa será fixada no menor valor

Fixo o regime inicial aberto.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas (art. 43, IV, c.c. o art. 46, ambos do Código Penal), a ser definida pelo Juízo de Execução Criminal.

Tendo em vista que os crimes foram cometidos em concurso material, as penas deverão ser somadas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar TIAGO HENRIQUE DE GASPARI FERREIRA, qualificado nos autos, às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 05 (cinco) dias-multa, por estar incurso no artigo 273, § 1º § 1-A, do Código Penal; e às penas de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, por encontrar-se incurso no artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98.

Substituto a pena de detenção por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, nos termos acima fundamentados.

Ante o fato de não estarem presentes os requisitos da prisão cautelar e em face da natureza da pena aplicada, poderá o acusado recorrer em liberdade.

Deixo de fixar valor indenizatório em favor da vítima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), por não haver instrução específica para esse fim, de modo a possibilitar ao réu o exercício de sua ampla defesa.

Decreto o perdimento dos bens apreendidos.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

P.R.I.

Limeira, 18 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA